

1500426-19.2021.8.26.0125

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES

Comarca: Capivari

Foro: Foro de Capivari

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... que o depoente, por ocasião do roubo, foi abordado pelo indivíduo que reconheceu pessoalmente (réu Rodolfo).

Em juízo, A.M.S. reconheceu os três réus como autores do roubo, estimando em 60% de certeza tal reconhecimento.

As testemunhas confirmaram a ocorrência do roubo, descrevendo a investigação realizada.

Ouvido em juízo como testemunha, o Policial Civil ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capivari

Foro de Capivari

2ª Vara

Rua Dr. João Adolfo Stein, 171, Capivari - SP - cep 13360-067

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500426-19.2021.8.26.0125 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500426-19.2021.8.26.0125

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Willian Araújo Grer e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE LUIZ MARCONDES PONTES

Vistos.

AMADEU OLIVEIRA DOS SANTOS, RODOLFO FELIPE LOPES TITO e WILLIAN ARAUJO GRER foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 157, §§ 2º, inciso I e 2ºA, c.c. o art. 29, ambos do Código Penal e, exclusivamente RODOLFO FELIPE LOPES TITO como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), porque, segundo narrou a denúncia, no dia 22 de março de 2021, por volta das 17h45min, na Fazenda Itapeva, município de Rafard, comarca de Capivari, Amadeu Oliveira dos Santos, Rodolfo Felipe Lopes Tito e Willian Araújo Grer, qualificados as fls. 84-133-181, e quatro outros homens não identificados, previamente acordados à prática de crime contra o patrimônio, mediante violência e ameaça exercida com armas de fogo, subtraíram para eles cinco tratores e uma caminhonete, pertencentes a H.V.M., A.M.S., N.A.M. e H.B.M. Para tanto, mantiveram A.M.S. e H.V.M. em seu poder, restringindo a liberdade de um e de outro; e na manhã de 29 de abril de 2021, no apartamento localizado na rua Avenida Ondas, 4604, bloco 5, nº 304, Piracicaba, Rodolfo Felipe Lopes Tito guardou, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para uso próprio, duas porções de maconha, substância tóxica que causa dependência física e psíquica.

A denúncia foi oferecida em 20/06/2021 (fls. 183/186) e recebida em 23/06/2021 (fls. 206/208).

O réu Rodolfo foi pessoalmente citado em 18/07/2021 (fl. 290) e apresentou sua resposta à acusação às fls. 302/307. O réu Amadeo apresentou sua resposta à acusação às fls. 365/384, fazendo-se presente por Advogado por ele constituído, suprimindo a necessidade de citação, conforme art. 570 do Código de Processo Penal. O réu Willian, finalmente, foi citado pessoalmente em 24/11/2021 (fl. 457), apresentando resposta à acusação juntada às fls. 482/485.

Realizada a audiência de instrução e julgamento (fls. 591/593), foram ouvidas as vítimas A.M.S. e H.V.M., além das testemunhas Gabriel (policial civil) e Ricardo (policial civil), e interrogados os réus.

Em seguida, o Ministério Público apresentou suas alegações finais em audiência. A Defesa manifestou-se em razões finais na forma escrita (fls. 615/630, 632/363, 654/660).

É o relatório. Passo a fundamentar.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não havendo quaisquer preliminares processuais alegadas pela Defesa ou pelo Ministério Público, passo, pois, a conhecer diretamente do mérito.

Destaco, antes, que a defesa de Amadeo suscitou a invalidade do reconhecimento fotográfico e do reconhecimento pessoal em juízo realizado por meio de videoconferência. Trata-se de questão de mérito e com ele será analisado.

A denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa se encontra devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/07, boletim de ocorrência de fls. 08/09, auto de entrega de fls. 10/15, auto de avaliação de fls. 278, laudo pericial papiloscópico de fls. 36/44, auto de constatação de fls. 78/79, auto de reconhecimento pessoal de fl. 82, auto de reconhecimento pessoal de fl. 83, laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 107/109, auto de reconhecimento fotográfico de fls. 118/122, auto de reconhecimento fotográfico de fls. 123/125, laudo pericial de fls. 256/259, laudo pericial de fls. 260/274, auto de avaliação de fls. 276/278,

De fato, inequívoca a ocorrência do roubo descrito na denúncia, o qual foi comprovado pela farta prova documental acima citada e pela prova oral colhida, em especial pelos depoimentos das vítimas, que descreveram, com riqueza de detalhes, os crimes que sofreram.

Eis a síntese da prova oral colhida.

Ouvido em juízo na condição de vítima, a Sr. H.V.M. contou que, no dia dos fatos, estava trabalhando na companhia de A.M.S.; que H.V.M. estava trabalhando com o trator e A.M.S. com outro maquinário; que, por volta das 20h00min, foi ao encontro de A.M.S., buscar uma peça do trator com que estava trabalhando; que, chegando lá, notou que estava acontecendo o roubo; que tentou fugir, mas não teve êxito e foi detido pelos assaltantes; que o depoente foi levado até o local em que se encontrava A.M.S. e permaneceu detido até ser liberado pelos assaltantes; que o depoente ficou preso junto ao maquinário, no meio do terreno, vigiado pelos assaltantes, enquanto outros realizavam a subtração; que eram sete assaltantes ao todo, sendo que cinco deles ficaram nas proximidades do depoente e outros dois ficaram na vigilância; que foram subtraídos cinco tratores, uma caminhonete, além de alguns materiais; que no momento em que o depoente tentou fugir, os assaltantes dispararam com arma de fogo; que os tiros foram disparados sem que fossem mirados no depoente; que permaneceu detido pelos roubadores das 20h00min às 02h00min; que os assaltantes levaram duas máquinas e depois levaram mais três; que as máquinas foram levadas por sua própria força motora (isto é, não foram levadas por guincho); que os roubadores tentavam disfarçar as vozes e ocultavam seus rostos com panos, camisas amarradas no rosto e máscaras cirúrgicas; que o depoente viu apenas os olhos dos roubadores; que foi chamado à Delegacia para participar de um reconhecimento; que viu uma pessoa na janelinha e aparentemente se tratava de um dos roubadores; que reconheceu tal pessoa com cerca de 70% de certeza; que ao lado da pessoa reconhecida foram colocadas outras pessoas perfiladas; que também participou de um reconhecimento fotográfico; que foi até a Delegacia e viu uma folha com várias fotografias e reconheceu duas pessoas que constavam na fotografia;

que era uma folha que continha várias fotografias; que a fl. 119 foi apresentada ao depoente por ocasião do reconhecimento fotográfico; que reconhece o número 4 da fotografia de fl. 119 como um dos autores do roubo; que tal reconhecimento se deu com cerca de 60% de certeza; que se recorda da fotografia de fl. 121 dos autos e não se recorda de ter reconhecido alguém que constasse nesta fotografia; que após o crime, ficou um tempo nervoso, mas já voltou ao normal.

Em juízo, a vítima H.V.M. reconheceu, sem absoluta certeza, os réus Amadeo e Rodolfo.

Ouvido em juízo como vítima, A.M.S. contou idêntica dinâmica do crime que o vitimou. Contou que estava trabalhando na companhia de H.V.M.; que por volta das 18h00min, chegaram os roubadores; que eram cerca de cinco pessoas e renderam o depoente; que o depoente ficou detido até cerca de 02h00min; que foram subtraídos cinco tratores e uma caminhonete; que os roubadores vestiam blusa, com camisetas no rosto e máscaras; que todos estavam encapuzados, deixando às mostras apenas os olhos; que esteve na Delegacia e participou de um reconhecimento, na Delegacia em Rio das Pedras; que havia quatro pessoas perfiladas e reconheceu uma delas com um dos roubadores; que o depoente reconheceu uma das pessoas pelo tom de voz; que reconhece com cerca de 60% a 70% de certeza; que além do tom da voz, reconheceu pela cor da pele e compleição física; que também participou de um reconhecimento fotográfico na Delegacia de Rafard; que, no reconhecimento fotográfico, foram apresentadas diversas fotos e reconheceu duas delas como de autores do roubo; que o reconhecimento fotográfico também estima em cerca de 60% a 70% de certeza; que foi-lhe apresentada a imagem de fl. 119 dos autos e reconheceu o indivíduo de número 4 (fotografia de Amadeo); que a fl. 121 dos autos reconheceu o réu William; que o depoente, por ocasião do roubo, foi abordado pelo indivíduo que reconheceu pessoalmente (réu Rodolfo).

Em juízo, A.M.S. reconheceu os três réus como autores do roubo, estimando em 60% de certeza tal reconhecimento.

As testemunhas confirmaram a ocorrência do roubo, descrevendo a investigação realizada.

Ouvido em juízo como testemunha, o Policial Civil Gabriel narrou, em breve síntese, que, após noticiado o roubo, foi coletada digital do réu Rodolfo em um dos maquinários subtraídos; que foi feito o levantamento dos locais em que Rodolfo poderia estar e foi cumprido o mandado de busca e apreensão; que, numa das residências, o réu foi localizado com sua esposa; que o depoente não estava na casa do réu Rodolfo por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão; que William e Amadeu são conhecidos nos meios policiais pela prática do delito; que acredita que, nas investigações posteriores, foi feita uma "ligação" entre Rodolfo e William e Amadeu; que o depoente participou da prisão de Amadeu e William posteriormente.

Ouvido em juízo como testemunha, o Policial Civil Ricardo narrou, em breve síntese, que, após noticiado o roubo, os veículos recuperados foram analisados e extraídas impressões digitais; que referidas amostras foram analisadas, identificando-se o réu Rodolfo como um dos autores do roubo; que foi realizada a busca e apreensão na casa de Rodolfo, ocasião em que se apreendeu o seu aparelho de telefonia celular; que William e Amadeu foram reconhecidos por fotografia como os participantes do roubo; que William e Amadeu foram relacionados ao envolvimento com Rodolfo pelo histórico criminoso, além de algumas referências.

Como se nota, inequívoca a ocorrência do roubo descrito na denúncia. As vítimas H.V.M. e A.M.S. descreveram, com riqueza de detalhes, o evento que vivenciaram: estavam trabalhando, quando indivíduos armados invadiram a propriedade e os renderam; tais indivíduos subtraíram, então, cinco maquinários agrícolas (tratores) e um automóvel do tipo pick-up. As vítimas permaneceram detidas pelos roubadores até que estes fossem definitivamente embora.

Contudo, a prova da autoria delitiva autoriza a condenação apenas do réu Rodolfo. Em relação aos demais, é excessivamente frágil.

Conforme relatado pelas testemunhas policiais civis, alguns dos maquinários foram abandonados pelos roubadores, localizados pela atividade policial e restituídos ao seu dono. Antes, contudo, foram submetidos à análise pericial, colhidas as

impressões papilares e analisadas. O resultado foi consignado no laudo de fl. 38, "o fragmento de impressão papilar sob nº 137220 coincide com o datilograma do dedo médio esquerdo do candidato registrado no sistema AFIS sob transação nº CC21T00024366746, referente a Rodolfo Felipe Lopes Tito".

Diante de tal robusta prova, Rodolfo foi submetido a reconhecimento pessoal, conforme termo de reconhecimento pessoal de fls. 82 e 83.

Conforme se depreende da leitura dos respectivos termos de reconhecimento, as vítimas, antes do reconhecimento propriamente dito, descreveram a pessoa a ser reconhecida. Em seguida, foram perfiladas três pessoas, de características físicas similares e apresentadas aos reconhecedores. Estes, por sua vez, reconheceram o réu Rodolfo como um dos autores do roubo.

As vítimas, ouvidas em juízo, confirmaram a higidez do procedimento adotado na Delegacia de Polícia, tendo sido observadas todas as formalidades prescritas pelo art. 226 do Código de Processo Penal.

Ambas as vítimas reconheceram, em juízo, o réu Rodolfo. Embora o reconhecimento judicial não tenha observado as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, entendo que tal reconhecimento é meramente complementar ao anterior reconhecimento realizado - este sim é essencial, deve seguir rigorosamente os ditames da lei e confere segurança ao reconhecimento realizado. Inegável, contudo, que, mesmo complementar, o reconhecimento judicial positivo contribui para corroborar a prova de autoria delitiva.

Diante desse conjunto probatório, entendo que a prova de autoria do delito em relação ao réu Rodolfo é robusta, autorizando a prolação do decreto condenatório com absoluta segurança.

Destaco que, muito embora as vítimas não tenham reconhecido o réu Rodolfo com absoluta segurança, o reconhecimento não é isolado, porquanto está corroborado pelo encontro de sua impressão papilar no maquinário subtraído. Ou seja, a autoria não decorre tão somente do reconhecimento, mas sim do reconhecimento associado ao fato de o réu ter tido contato manual, logo após o crime, com o maquinário subtraído por ocasião de sua ocorrência.

Ainda, a justificativa dada pelo réu, de que teria trabalhado com o maquinário no qual foi encontrada a sua impressão papilar, é inverossímil.

De fato, quando interrogado, o réu Rodolfo confessou a posse das porções de maconha; declarou que referidas porções eram para o seu consumo próprio; que, em relação ao roubo, confirma que teve contato com as máquinas, mas não sabia que elas eram produto de crime; que foi contratado por um rapaz para manobrá-las; que conduziu a máquina para o caminhão que a levou embora; que não viu ninguém armado; que isso se deu em uma frente de trabalho.

Ocorre que os veículos foram localizados no dia seguinte ao do roubo. O roubo ocorreu no dia 22/03/2021 e foi localizado abandonado, em local ermo, no mesmo dia de sua comunicação à autoridade policial (conforme boletins de ocorrência de fls. 04/07 e 08/09). Não é verossímil, revelando incompatibilidade com as regras da experiência e com aquilo que normalmente ocorre, que os veículos tenham sido subtraídos num dia e, neste mesmo dia, tenha sido operado em um trabalho lícito e abandonado logo em seguida.

Trata-se, na realidade, de mera alegação fantasiosa com o fim de se furtar à responsabilidade criminal que lhe cabe. Em suma, a prova de autoria delitiva em relação ao réu Rodolfo é robusta e autoriza a sua condenação com a necessária segurança.

Por oportuno, em relação à posse de drogas para o consumo próprio, as testemunhas confirmaram a apreensão da droga, confessada pelo réu, o qual informou que era para o seu consumo próprio. Bem comprovada, portanto, a prática do crime tipificado no art. 28 da Lei de Drogas.

Quanto aos demais réus, a prova de autoria delitiva é frágil.

De fato, a autoria, em relação a eles, reside apenas e tão somente no reconhecimento fotográfico realizado.

Os reconhecimentos fotográficos foram frágeis. As próprias vítimas informaram que sua certeza, quanto ao reconhecimento realizado, era de 60 ou 70%. Quando indagadas, afirmaram que não podiam assegurar a autoria com absoluta certeza. Em

outras palavras, nenhuma das vítimas reconheceu os réus Willian e Amadeu com a segurança necessária e exigida para o decreto condenatório. O reconhecimento judicial, de igual modo, não foi seguro.

Aliás, destaco que a vítima H.V.M. não reconheceu por fotografia o réu Willian, mas apenas o réu Amadeu, conforme auto de fl. 125. A mesma foto de Willian foi reconhecida pela vítima A.M.S., e este o reconheceu como um dos autores do roubo. As vítimas tinham poucos elementos para realizar o reconhecimento, porquanto, como narraram, os roubadores estavam com a maior parte de suas faces ocultas por máscaras ou camisetas. Logo, o reconhecimento fotográfico, o qual ocorre exclusivamente por meio dos traços faciais (já que as fotos abrangeram apenas os rostos dos suspeitos), torna-se ainda mais fragilizado, pois, em rigor, apenas os olhos dos roubadores foram efetivamente vistos pelas vítimas. Tal cenário é insuficiente para que o reconhecimento fotográfico indique qualquer segurança. Finalmente, o alegado envolvimento dos réus Willian e Amadeu com Rodolfo não ficou demonstrado. De fato, há prova de que Willian de fato conhece o réu Rodolfo, mas não há nenhuma conversa no laudo de fls. 260/274 entre Willian e Rodolfo, embora Willian seja mencionado; mas a referência feita a Willian não demonstra que ele tenha participado no roubo em questão.

Acerca do reconhecimento fotográfico, recente julgado do STJ, com absoluta razão, entendeu pela fragilidade de tal meio de prova.

O reconhecimento exclusivamente fotográfico não pode ensejar a condenação e, com igual razão, também não pode servir de fundamento exclusivo à prisão cautelar.

Não se trata de mero rigorismo ou apego excessivo ao formalismo.

É que o reconhecimento fotográfico macula o reconhecimento pessoal e este, quando não é realizado com a observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, acaba servindo de prova frágil à condenação.

Não se ignora que, por vezes, o reconhecimento pessoal, embora realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, pode contribuir para a fundamentação da condenação, mas apenas quando existirem outros elementos de prova de autoria delitiva.

Porém, é muito importante destacar que, em se tratando de crimes patrimoniais, em que não há qualquer vínculo anterior entre o autor do crime e a vítima, o reconhecimento irá consistir no único meio de prova disponível para o estabelecimento da autoria. Assim, especialmente em razão da falta de outras provas, é imperioso que o reconhecimento seja realizado de forma absolutamente segura e seguindo-se o procedimento estabelecido no art. 226 do CPP, pois tal reconhecimento será a única prova a fundamentar eventual condenação.

Não se trata de rigorismo. O art. 226 do CPP estabelece um procedimento razoável que traz segurança ao reconhecimento, de modo a minorar drasticamente o risco de reconhecimentos equivocados.

Recente julgado do STJ, dando novos contornos ao tema, rechaçou o reconhecimento pessoal realizado sem a estrita observância do art. 226 do CPP. A ementa da decisão muito bem destaca os problemas da anterior abordagem, que considerava que o procedimento de reconhecimento estabelecido no art. 226 do CPP consistia em mera recomendação do legislador.

Com razão, pois, como dito acima, o procedimento estabelecido no art. 226 do CPP constitui mecanismo razoável para que o reconhecimento pessoal seja realizado com a segurança necessária para fundamentar isoladamente uma condenação criminal.

Veja-se o seu teor:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.

NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os

equivocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciais e, conseqüentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciais (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua insita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). 9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento – sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo – ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado. 10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua conseqüente

absolvição, ante a inexistência, como se defluiu da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado. 11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito – conforme reconheceu o Magistrado sentenciante – emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância). 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão – SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação. (STJ, HC 598.886, Sexta Turma, Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, j. 27/10/2020).

Deste modo, considerando a fragilidade do reconhecimento fotográfico, o qual é isolado no conjunto probatório, porquanto não corroborado por outras provas, há insuficiente probatória a autorizar um decreto condenatório em relação aos réus William e Amadeu.

Passo a dosar a pena.

Conforme certidão de fls. 225/227, Rodolfo é reincidente específico (autos 0006014-20.2014.8.26.041, data do fato 09/04/2014, trânsito em julgado 12/02/2019, tipo penal art. 157, § 2º, incisos I e II; e autos 0006514-57.202.8.26.0451, data do fato 08/03/2012, trânsito em julgado em 02/02/2015, tipo penal art. 157, § 2º, incisos I e II; autos 0000904-88.2014.8.26.01629, data do fato 10/12/2013, trânsito em julgado 18/08/2016, tipo penal art. 157, § 2º, incisos I e II).

Diante de tal histórico, uma das condenações será valorada como antecedente, na primeira fase da dosimetria da pena e, as demais, como reincidência, na segunda fase.

Dessa forma, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria da pena, fixo a pena-base exasperada em 1/4, considerando os antecedentes do condenado, bem como a circunstância de que embora tenha atingido um único patrimônio, envolveu duas vítimas, submetidas à grave ameaça, e finalmente, considerando o expressivo valor dos objetos subtraídos (mais de R\$ 400.000,00), perfazendo 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a circunstância agravante da reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal, agravo a pena em 1/5, considerando que a reincidência é específica, além de se tratar de duas anotações, fixando-a, nesta fase, em 6 anos de reclusão e 14 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de redução de pena a serem consideradas. Estão presentes, contudo, a causa de aumento de pena do § 2º, inciso II ("se há o concurso de duas ou mais pessoas"); inciso V (se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.) e § 2º-A inciso I ("se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;"). Considerando, portanto, a incidência de três causas de aumento de pena, bem como que foram muito mais que duas pessoas que praticaram o roubo, que várias delas faziam uso de arma de fogo, que as duas vítimas permaneceram detidas das 20h00min às 02h00min, tratando-se de longo período de verdadeiro terror que vivenciaram, aplicado ambas as causas, respectivamente, 1/3 e 2/3, perfazendo 13 anos e 4 meses de reclusão e 30 dias-multa.

De fato, entendo inadequado, no caso, aplicar-se um só dos aumentos, pois, além de ser faculdade do juiz na dosimetria da pena, considero que a gravidade em concreto das causas de aumento desautorizada a opção por uma única delas, pois foram cinco os agentes do crime (e o concurso de duas pessoas já faz incidir o aumento de pena, tratando-se de conduta muito mais reprovável a prática do crime por um grupo criminoso), sendo certo que vários deles portavam arma de fogo (tratando-se de conduta mais grave, comparativamente àquela quando apenas um dos roubadores porta a arma), além de incidir mais de uma causa de aumento de pena do § 2º (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima).

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.º 13.654/2018. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NO SENTIDO DE SER VEDADO O CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO SOMENTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição a recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 12/03/2015).

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. - Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015)

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, "D" E "I". ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, "A") E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE "FOTOGRAFIAR" MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM

REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. A conduta consubstanciada em “fotografar” cenas com pornografia envolvendo crianças e adolescentes amolda-se ao tipo legal previsto no art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), com redação dada pela Lei nº 10.764/2003, notadamente à expressão “produzir fotografia”, cujo valor semântico denota o comportamento de “dar origem ao registro fotográfico de alguma cena”. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 241 do ECA, em razão de ter fotografado sua enteada de seis anos de idade em cenas de sexo explícito. Tipicidade da conduta devidamente caracterizada e apenada. 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. 6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual. (HC 110960, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014)

Tratando-se de réu reincidente, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, “a”, considerando que a primariedade do condenado constitui requisito objetivo para a fixação de regime mais brando. Deixo de aplicar o art. 387, parágrafo segundo, Código de Processo Penal, isto é, computando o tempo de prisão provisória para a definição do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que não há nos autos elementos que permitam a aferição da conduta carcerária do réu, de forma que ao juízo da execução é que cabe, assim que receber a guia de execução, provisória ou definitiva, avaliar a possibilidade de detração e progressão do réu a regime menos afliitivo.

Na falta de comprovação da capacidade econômica do réu, arbitro o dia-multa no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacionalmente unificado vigente ao tempo da prática do delito e atualizado pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais divulgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o efetivo pagamento.

Quanto ao crime do art. 28 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), fixo a pena de advertência, por entender adequada e suficiente ao caso.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a denúncia para (i) ABSOLVER AMADEU

OLIVEIRA DOS SANTOS e WILLIAN ARAUJO GRER da imputação do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2-A, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e (ii) CONDENAR RODOLFO FELIPE LOPES TITO como incurso nos artigos 28 da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas) e 157, § 2º, incisos II e V, e § 2-A, do Código Penal, às penas de, respectivamente, advertência sobre os efeitos das drogas e 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado segundo o INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática para Atualização de Débitos Judiciais do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo até o efetivo pagamento.

O réu RODOLFO não tem o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo respondido ao processo preso, seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Ora, se o réu aguardou a instrução criminal preso cautelarmente, sem haver qualquer alteração fática, não há qualquer motivo para soltá-lo justamente quando sentença condenatória é proferida. Nesse sentido: "Com efeito, nota-se que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal e, em inexistindo elementos novos a influir na análise acerca da necessidade da custódia cautelar, incabível a sua libertação. Ainda mais agora que conta com sentença condenatória em seu desfavor (...)" (TJ SP, HC 990.10.459136-8, 16.^a C., rel. Almeida Toledo, 14.12.2010, v. u.). Ademais, o réu é reincidente específico, ostentando outras três condenações pela prática de roubo, indicando risco concreto de reiteração delitiva. Finalmente, a pena dosada é convidativa à fuga, gerando fundado risco à aplicação da lei penal.

Condenação à taxa judiciária. Condene o(s) réu(s), na forma do art. 804 do Código de Processo Penal e da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º, ao pagamento da taxa judiciária, observado, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio, o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil ("Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.")

Expedição de certidão do Convênio OAB/DPE. Em caso de defesa patrocinada por meio do Convênio OAB/DPE, aguarde-se o decurso do prazo para interposição de recurso. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários (para pagamento de 100% do valor previsto na tabela). Na hipótese de interposição de recurso por qualquer uma das partes, expeça-se certidão de honorários, observando-se a seguinte regra do Convênio: "nos processos criminais de competência do Juízo singular, após a sentença condenatória ou absolutória com interposição de recurso por quaisquer das partes, 70% (setenta por cento) do valor previsto na tabela por ocasião da sentença e, os 30% (trinta por cento) restantes, após o trânsito em julgado do acórdão."

Expedição de guia de execução provisória. Interposto o recurso, em caso de réu(s) preso(s), expeça-se guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado, (a) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); (b) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (c) expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Oficie-se à 13ª Câmara de Direito Criminal, Habeas Corpus Criminal 2103101-53.2022.8.26.0000, informando do julgamento, com cópia desta sentença.

P. I.

Capivari, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA